



תיק מס' 18/13

המפקח על רישום מקרקעין בעכו
בפני כב' המפקח יובל וסרקרוג

בעניין:

1. טראו רינה,

2. טראו אריאל,

ע"י ב"כ עו"ד משה לוי ו/או אח'

שד' פל-ים 2 "חלונות הסיטי" בניין אורן, חיפה - הנתבעים

נגד

דוד קדוש,

ע"י עו"ד רפאל לוריג ואח'

שדרות הגעתון 45 נהריה - הנתבע

פ ס ק - ד י ן

בהליך זה מבקשים התובעים כי אתן צו אשר ימנע מהנתבע לבנות את המרפסת המבוקשת על ידו ברכוש המשותף וזאת בהתאם להיתר בניה שקיבל.

1. עסקינן בבית הרשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים, הידוע כגוש 18174 חלקה 30 ומצוי ברחוב רמז 39, נהריה.

2. הבית מורכב משמונה דירות, כאשר התובעים הנם בעלים של תת חלקה 3, בעוד הנתבע הינו בעלים של תת חלקה 1. דירת התובעים נמצאת מעל דירת הנתבע.

3. דירת הנתבע הינה דירת קוטג', הממוקמת בשני מפלסים – קומת קרקע וקומה ראשונה. דירת התובעים ממוקמת בקומה השנייה (קומה מעל).

4. לפני מספר שנים הרחיב הנתבע את דירתו במפלס הקרקע. על גג החלק שהורחב הקים גג רעפים. להרחבה זו קיבל את הסכמת הדיירים ובהם התובעים. הרחבה זו אינה נושא הדיון בפניי.

5. כעת מבקש הנתבע לעשות שימוש בגג של אותו חלק שכבר הורחב על ידו בעבר, וזאת על דרך החלפת גג הרעפים בגג שטוח וכן בנייתה של מרפסת פתוחה כהמשך למרפסת קיימת במפלס השני של דירתו (קומה ראשונה של הבניין). יודגש כי בניית המרפסת תעשה כל כולה על גבי שטח גג שכבר קיים כיום, ואין בבנייה המבוקשת משום יצירת "בליטות" חדשות או חריגה מקווי הבניין הקיימים כיום.



6. לצורך כך הגיש הנתבע לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות, בקשה להיתר (נ/1) עליה חתמו כל יתר בעלי הדירות בבניין, למעט התובעים (משמע ששה בעלי הדירות). הנתבע ביקש כאמור להגדיל את המרפסת הקיימת בכ-30 מטר, זאת לאחר הפיכת הגג הקיים לגג שטוח.
7. התובעים הגישו התנגדותם לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ושם פירטו את הפגיעה שתגרם לשיטתם בעקבות בנייתה של אותה מרפסת. הוועדה המקומית החליטה בסופו של יום לדחות את ההתנגדות וביום 23.1.2013 ניתן לנתבע היתר לבניית המרפסת בשטח של כ-29.6 מטר.
8. על החלטת הוועדה המקומית לא הגישו התובעים ערר לוועדת הערר המחוזית. ב"כ התובעים ציין כי לצורך קבלת ההיתר לא נדרשה הקלה (עמ' 1 לפרוט' מיום 20.3.2013).
9. ביום 11.3.2013 הגישו התובעים בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, במסגרתה ביקשו למנוע מהנתבע להקים המרפסת עד להכרעה בתביעה העיקרית. בדיון שהתקיים בפניי במעמד הצדדים ביום 20.3.2013 הגיעו הצדדים לידי הסכמה כי מבלי שהדבר יהווה הודאה במי מטענות הצדדים, הרי שעד להחלטה אחרת הנתבע לא יבנה את המרפסת שביקש אלא רק יאטום את הגג וכן יבצע העבודות הדרושות לצורך ניקוז המים על הגג (בשים לב לכך שגג הרעפים כבר הוסר).

טענות הצדדים בתמצית

10. **התובעים** טוענים כי לצורך בניית המרפסת נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות, כי סעיף 71 לחוק המקרקעין אינו חל על בניית מרפסת. לחילופין, נטען כי אפילו חל סעיף 71 לחוק, כי אז לא נתקבלה הסכמת רוב בעלי הדירות נוכח חזרתם של חלק מבעלי הדירות מהסכמתם ו/או משלא ניתנה הסכמה לבניית המרפסת, שכן חלק מהדיירים הוטעו.
11. עוד נטען כי ההחלטה נשוא ההליך צריכה הייתה להתקבל רק במסגרת האסיפה הכללית, ולא די בהסכמות הפרטניות של בעלי הדירות. עוד נטען כי אפילו נתקבלה הסכמת הרוב הדרוש, הרי שהבנייה המבוקשת עולה כדי פגיעה מהותית בזכויות התובעים כמשמעותה בסעיף 71 לחוק, ודי בכך כדי למנוע הבנייה ברכוש המשותף.
12. **הנתבעים** מצדם טוענים כי הפסיקה הכירה בכך כי סעיף 71 חל גם על בניית מרפסת, כי אין צורך לקבל החלטה על הרחבת דירה במסגרת אסיפה כללית, כי הלכה למעשה יש להם הרוב הדרוש, שכן כל בעלי הזכויות חתמו על הבקשה להיתר, הוסברה להם היטב מהות הבקשה ואין להכיר בבקשת חלק מהדיירים לחזור בהם מהסכמתם, במיוחד משלא נחקרו (למעט שכנה אחת) וכי ממילא לתובעים לא תגרם כל פגיעה מבניית המרפסת, ודאי שלא פגיעה העולה כדי פגיעה מהותית.



דיון

13. בהליך זה עליי לדון בשתי טענות מרכזיות. **האחת** - האם יש בידי הנתבע את ההסכמות הדרושות מבין בעלי הדירות לצורך בניית המרפסת. ככל שהמסקנה תהא חיובית, כי אז אדרש לשאלה **השנייה** – האם בניית המרפסת תהווה פגיעה מהותית בזכויות התובעים.

שלב א' - האם יש בידי הנתבע את ההסכמות הדרושות לצורך בניית המרפסת

14. התובעים טוענים כי לצורך בנייתה של המרפסת היה על הנתבע להשיג את הסכמת כל בעלי הדירות, ועל כן נוכח התנגדותם די בכך כדי להעתר לתביעה.

יש לדחות טענה זו.

15. אכן ככלל הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, ודאי שלצורך בניה על אותו חלק שהוצמד, מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות (סעיף 62 לחוק). **החריג** לכלל זה הינו כאשר עסקינן ב"הרחבת דירה" כמשמעותה בסעיף 71 לחוק המקרקעין שהוסף לחוק במסגרת תיקון 18 בשנת 1995.

16. סעיף 71 לחוק המקרקעין, קובע רף הסכמה נמוך יותר לצורך "הרחבת דירה". בהתאם לסעיף זה די בהסכמה של 75% מבעלי הדירות אשר צמודים לדירותיהם 2/3 מהרכוש המשותף, כדי לאשר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף וכן הצמדתם לדירה מסוימת: **"לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה"**.

17. על כן, השאלה המתעוררת הינה האם בנייתה של מרפסת עולה כדי "הרחבת דירה", שאז די בהסכמת רוב מסוים מבעלי הדירות כמפורט לעיל ובסעיף 71 לחוק, אחרת נדרשת כאמור הסכמת כל בעלי הדירות בהתאם לסעיף 62 לחוק.

18. המונח הרחבת דירה הוגדר בסעיף 71א לחוק כדלקמן:

"הרחבה" - הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף".

פרשת עטיה –

19. פרשנותו של המונח "הרחבה" נדונה בבית המשפט העליון בפרשת עטיה. שם ציין בית המשפט כי:

"בלשון החוק אין התייחסות לשאלת הצמידות הפיסית של התוספת לשטח הדירה. כל שהמחוקק גילה לנו בשפת החוק הוא כי "הרחבה" מגדילה את שטח הרצפה של הדירה המורחבת." (רע"א 1462/10 דוד עטיה נ' ליאור שגיא, פסק דין מיום 2.8.2012 (פורסם באתר נבו) להלן - **"פרשת עטיה"** (ההדגשות אינן במקור)).



20. השאלה שנדונה בפסק דין עטיה הייתה :

"האם בניית מחסן בשטח משותף והצמדתו לדירה פלונית, שאינה בסמיכות פיסית אליו, יכולה להיחשב כ"הרחבת דירה" (ההדגשות אינן במקור).

לצורך מענה על שאלה זו עמד בית המשפט העליון בפרשת עטיה על התכלית שבבסיס תיקון 18 לחוק :

"המטרה שאותה ביקש המחוקק להגשים באמצעות דבר החקיקה הייתה להקל על מצוקת הדיור ולאפשר ניצול יעיל יותר של הקרקע על-ידי הרחבת הדירות. זאת באמצעות הפחתת כוחו של המיעוט, ונטילת "זכות הווטו" שלו באשר להחלטות הנוגעות לרכוש המשותף שעניינן הרחבת דירה"

בסופו של יום הגיע בית המשפט הנכבד למסקנה כי :

"הדרישה לסמיכות פיסית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות הדיור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף" (ההדגשות אינן במקור).

21. הנה כי כן, בית המשפט העליון בפרשת עטיה קבע כי כדי שבנייה ברכוש המשותף תחשב "כהרחבת דירה" נדרשת **"סמיכות פיסית"** בין הדירה לבין "ההרחבה". אין חולק כי תנאי זה מתקיים בעניינו.

22. לכך ניתן להוסיף מספר פסקי דין בהם נקבע במפורש, כי בנייתה של מרפסת תחשב אף היא כ"הרחבת דירה" לצורך סעיף 71 לחוק המקרקעין.

23. כך גם פסק לאחרונה בבית המשפט המחוזי בחיפה בעש"א (חי') 50945-05-12 **יובל ברק נ' דבורה קרש**, פסק דין מיום 19.5.2013 (פורסם בנבו). שם ראה בית המשפט כמובן מאליו בבנייתה של מרפסת משום הרחבת דירה :

"בניית המרפסת הזיזית היא בדרך הרחבת דירת המערערים, וחלים עליהם הכללים הקבועים בסעיף 71(ב)א לחוק המקרקעין. למעשה הדיון שלעיל, בשאלת התקנת משטח ה"דק", חל גם בעניין המרפסת הזיזית, המהווה הרחבת דירתם של המערערים."

וקודם לכן קבע בית המשפט הנכבד באותה פרשה כי :



**"אילו המערערים היו מבקשים להוסיף לדירה מרפסת פתוחה (תלויה),
כי אז לא הייתה מחלוקת, שבניית המרפסת הייתה מרחיבה את דירת
המערערים".**

24. מסקנה זו מתיישבת עם לשון החוק והן עם תכלית התיקון, כפי שפורטה בהרחבה בפסק דין של בית המשפט העליון בפרשת **עטיה**, שכן בנייתה של מרפסת עשויה אף היא להקל על צפיפות הדיור ומשיקה פיסית לדירת הנתבע (בעניין זה ראה גם פסק דינו של המפקח ש' הילזר בתיק 27/12 **נורית מור נ' יורם זיו אור** (פורסם בנבו) וכן פסקי הדין המוזכרים שם, ובהם פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים בע"א 1415/00 **אברהם נ' אזרז** (לא פורסם)).

25. זאת ועוד, בית המשפט העליון שדן בפרשת **עטיה** בהרחבה בתיקון 18 לחוק וכן בתכליות שעמדו בבסיס סעיף 71 לחוק, לא מצא להגביל את הפרשנות שיש ליתן למונח "הרחבה" של דירה, למעט אותה השקה פיסית לדירה עצמה.

26. בנסיבות אלה, הציטוטים אליהם הפנו התובעים בסיכומיהם מפסק דין עטיה אינם תומכים בטענות הנטענות על ידם, ואינם מתיישבים עם האמור בפרשת עטיה ועם השאלה שעמדה שם במחלוקת.

27. התוצאה מן המקובץ לעיל הינה כי בענייננו חל סעיף 71 לחוק, ועל כן די ברוב של 75% מבעלי הדירות, ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כדי לאשר ההרחבה המבוקשת.

28. יש לדחות גם את טענת התובעים, שבשל העובדה שהנתבע מתגורר בדירה בגפו, לא מתקיימת התכלית שבתיקון 18 שנועדה להקל על צפיפות הדיור. ככל שהנתבע מילא אחר התנאים שקבע המחוקק והפסיקה (כך בפרשת עטיה) לצורך הרחבת הדירה, די בכך כדי לאפשר לו להרחיב את דירתו. המחוקק לא קבע כי יש לבחון בכל מקרה ומקרה אם אכן ההרחבה תקל בפועל על צפיפות הדיור, אם לאו, כתנאי לאישור ההרחבה.

האם לנתבע יש את הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 71 לחוק

כללי ונטל הוכחה

29. ככלל, מקום בו מבקש בעל דירה לבצע הרחבה על הרכוש המשותף, עליו הנטל להוכיח כי יש בידו את ההסכמה הנדרשת לכך בחוק. ויודגש, על מבקש ההרחבה להוכיח הסכמה פוזיטיבית לבניה המבוקשת, והוא לא יוכל לטעון להסכמה בהיעדר התנגדות של בעל דירה אחרת.



30. יחד עם זאת, מבקש ההרחבה יצא ידי חובתו, בהצגת מסמך המעיד על הסכמה מפורשת כאמור, וככל שהציג מסמך כזה, הנטל להפריך את ההסכמה חוזר לכתפי התובעים.

31. כך פסק כב' המפקח הבכיר ש' הייזלר בתיק 60/11 **ערן אליצור ואח' נ' ענת אלפי** (פסק דין מיום 1.8.2012 פורסם באתר משרד המשפטים, להלן – "**פרשת אליצור**"), תוך שהוא מפנה למספר מקורות עליהן ביסס קביעה זו:

"**חתימת בעל הדירה על תכנית בניה המוגשת לרשויות התכנון, אכן עשויה להוות ראיה טובה לכך כי הוא הסכים לבניה המבוקשת...כל אימת שברור מההסכמה שהוצגה לצורך מתן היתר הבניה, כי בעל הדירה ידע מה מהותה של הבקשה והסכים לבניה המבוקשת, יש לראות בכך הסכמה מצדו להרחבת הדירה וניצול אחוזי הבניה במסגרת סעיף 71 לחוק [השווה עוד: ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4), 673, וכן מ. דויטש, קניין [א], 695]**"

32. משחתמו בעלי הדירות על תכנית הבניה שהוגשה לוועדה המקומית, עובר הנטל לתובעים להוכיח כי בעלי הדירות הוטעו ו/או חזרו בהם מהסכמתם. ראה למשל פסק דינה של כב' המפקחת ליבוביץ בעניין **גבריאלי**. באותה פרשה נפסק, כי אין לאפשר לבעל דירה, לאחר שחתם על תוכניות, לחזור בו מהסכמתו בהעדר טעם ממשי לכך:

"**לא יתכן ליצור מצב שבו כל אחד מבעלי הדירות האחרים יוכל "למשוך את השטיח" בכל רגע נתון ולעצור את התהליך משום שהחליט לשנות את עמדתו וזאת לאחר שהצד שלו ניתנה ההסכמה הסתמך על אותה הסכמה והשקיע ממון בגינה "** (י' ליבוביץ בתיק 87/11 (חי') **גבריאלי נועם ואח' נ' בוזגלו איריס ואח' (פורסם בנבו) להלן - "פרשת גבריאלי"** וכן ע"א 815/81 **יעקב כליפא נ' אלי שאול**, פ"ד לו(3), 78).

מן הכלל אל הפרט

33. בענייננו, הציג הנתבע בקשה להיתר עליה חתמו כל בעלי הדירות בבניין, למעט התובעים (1/ו-2). התובעים טוענים כי חלק מבעלי הדירות הוטעו לחשוב כי הנתבע מבקש רק להחליף את גג הרעפים בגג שטוח ולא נתנו הסכמה לבניית המרפסת.

34. בענייננו, כאמור, כל בעלי הדירות (למעט התובעים) חתמו על הבקשה להיתר, ועל כן יש להניח כי היו מודעים לטיב העבודות אותן ביקש הנתבע לבצע. הדבר עולה הן מהתשריט של הבקשה עצמו והן מתיאור הבקשה בגרמושקה (1/ו):

"**החלפת גג רעפים קיים בקומה א' בגג שטוח מבטון והפיכתו למרפסת גג "**

35. מהעדויות שהובאו בפניי, אינני מקבל גם את הטענה כי הנתבע לא הסביר לשכנים, כי בכוונתו להחליף את גג הרעפים במרפסת. התובעת עצמה אישרה בעדותה כי כאשר



הנתבע פנה אליה ולבעלה וביקש לקבל את הסכמתם לבקשה להיתר, הרי שמהתוכנית שהציג בפניה ניתן היה להבחין בנקל כי בכוונתו להקים מרפסת:

"את התוכנית עצמה ראיתי בחטף, כי הבנתי מהר מאוד את משמעותה, שעומדת לקום מרפסת" עמ' 6 ש' 12 לפרוט' מיום 18.4.2013.

36. אם כך, התובעת אישרה כי מהבקשה להיתר ניתן היה להבין בנקל את אשר מבוקש לאשר.

37. זאת ועוד, בענייננו, על סמך אותן הסכמות בכתב על גבי הגרמושקה, הוגשה הבקשה להיתר, הנתבע מילא אחר התנאים שנדרשו על ידי הוועדה המקומית והוציא כספים שונים לצורך הוצאת ההיתר. התנגדות התובעים נדונה בפני מוסדות התכנון ונדחתה. ודאי שאין מקום לאחר כל ההליך בפני הוועדה המקומית לאפשר לבעלי דירות לחזור בהם מהסכמתם, בהעדר טעם ממשי המצדיק זאת.

38. בנוסף, הטוען כי חתם על מסמך מבלי להבין את תוכנו, עליו הנטל להוכיח כי אכן כך היה. ניתן עוד להניח כי אם אכן מי מיתר בעלי הזכויות סבר שהוטעה ושהבנייה המבוקשת תפגע בזכויותיו, היה ממהר להגיש התנגדות לוועדה המקומית ו/או לכל הפחות מתייצב להחקר בפניו על עניין זה. פעולות אלה לא נעשו ולמעשה, למעט התובעים, (וליתר דיוק התובעת לבדה) איש מבעלי הדירות בבניין לא טען כי הבנייה המבוקשת תפגע בו.

39. כאמור, על הבקשה להיתר חתמו כל בעלי הדירות בבניין, למעט התובעים. התוצאה 7/8 אשר להם 89/100 חלקים מהרכוש המשותף הסכימו להרחבת הדירה.

עמדות השכנים

40. להלן אפרט ואתייחס ל"התנגדויות" שפורטו במכתבים של שכנים, כפי שצורפו לבקשה לסעד הזמני של התובעים:

א. משפחת פרייטג ציינה:

**"הנני חוזר בי מהסכמתי לבקשת מר קדוש דוד להחליף את גג הרעפים בגג בטון ובניית מרפסת במקום גג הרעפים
חתמתי בעקבות אי ידיעה שיש לקיים אספת דיירים בה יוכל כל אחד להשמיע את טיעוניו כולל הנפגעים משפחת טראו".**

ב. משפחת טהורי ציינה:

"לאחרונה, פנתה אלינו מש' טראו, והסבירה את התנגדותה לבניה..."



היות וכך, והיות ואין ברצוננו לקבוע עמדה במחלוקת, אנו מבקשים להשעות את הסכמתנו לבניה, עד אשר יגמר הבירור בהתנגדות מש' טראו, אצל המפקחת על רישום המקרקעין."

41. שני המסמכים הנ"ל לא נערכו כתצהיר וממילא מי שערך אותם לא זומן למתן עדות. די בכך כדי שלא ליתן להם משקל כלשהו. יתרה מכך, שני השכנים הללו **אישורו כי אכן חתמו** על התוכניות, **לא טענו כי הוטעו**, וממילא לא טוענים במפורש כי הם מתנגדים לבנייה המבוקשת.

התנגדות השכנות גב' בן ישי וגב' לודביש
42. שתי שכנות נוספות, הגב' לודביש (אשר לה 14/100 חלקים ברכוש המשותף) והגב' אורה בן ישי (אשר לה 10/100 חלקים ברכוש המשותף), טענו כי הנתבע הציג בפניהן בקשה להחליף את גג הרעפים לגג בטון בלבד, ללא אזכור בקשתו לבניית מרפסת. שתי אלה הודיעו כי הן חוזרות בהן מהסכמתן להחליף את גג הרעפים בגג בטון ובניית מרפסת ואף הגישו תצהירים. מנגד, רק הגב' לודביש נחקרה על תצהירה. בתצהירה טענו כדלקמן (תוכנם של שני התצהירים היה זהה):

"אני מאשרת שנית שקדוש(הנתבע – תוספת שלי) לא הסביר לי את רצונו להקים מרפסת, אלא אמר לי שהוא מעוניין לפרק את גג הרעפים בלבד וחוזרת על התנגדותי להקמת המרפסת על ידי קדוש"

43. אציין כבר כעת, אינני מקבל את שתי ההתנגדויות ואין לאפשר לשכנות אלה לחזור בהן מההסכמה שניתנה. מדובר בהתנגדות מאוחרת שניתנה במסגרת ההליך הנוכחי, לאחר שהגב' לודביש והגב' בן ישי כבר **חתמו על התוכניות** שהוגשו לוועדה המקומית ו**בהעדר טעם ממשי להתנגדות** או לשינוי בעמדתן. בתצהירה של הגב' לודביש והגב' בן ישי, לא נכלל נימוק כלשהו העומד בבסיס ההתנגדות, ולא ניתן כל הסבר מדוע הבנייה המבוקשת תפגע בהן.

44. נהפוך הוא, הגב' לודביש הדגישה פעם אחר פעם במסגרת חקירתה הנגדית כי היא עצמה לא מתנגדת וכי בקשת הנתבע לא מפריעה לה:

**"ש' – זה מפריע לך מה שקדוש מבקש לבנות?
ת' – לי אישית לא מפריע. אני לא מתנגדת אני לא הסכמתי"**

ובהמשך:

**"ש' – אני שואל אותך האם את עצמך מתנגדת?
ת' – אני אישית לא מתנגדת, לי זה לא מפריע" (עמ' 3 לפרוטוקול מיום 8.5.2013 ש' 16 – 24, ההדגשות אינן במקור)**



45. הפסיקה הורתה כי המפקח מוסמך, בנסיבות מסוימות, לבחון את מידת תום ליבו של המתנגד וכן את הטעמים העומדים בבסיס ההתנגדות ולא די בהתנגדות סתמית בעלמא (ר' למשל עש"א 13877/09 אילן קיסרי נ' שאחב שלומוב (חיפה) [פורסם בפדאור] עש"א 17181-05-11 אברהם נ' פדאל ואח' [פורסם בפדאור]).
46. לצורך המקרה שבפניי אינני נזקק לשאלת היקף התערבות המפקח בנימוקי ההתנגדות ומידת תום הלב של מי מהצדדים, שכן הלכה זו נכונה על אחת כמה וכמה כשעסקינן בחזרה מהסכמה שניתנה ו/או טענת הטעיה לגבי הסכמה שניתנה.
47. על כן, לא די בהתנגדות הסתמית כפי שפורטה בתצהירים לצורך חזרה מהסכמה שניתנה, במיוחד משלא נחקר אותו "מתנגד" על תצהירו (הגב' בן ישי), והמצהירה האחרת (הגב' לודביש) אישרה כי הבניה כלל לא מפריעה לה ולמעשה אף אינה מתנגדת למבוקש.
- אי התייצבותה של הגב' בן ישי למתן עדות**
48. אציין כי למרות שגיליתי אורך רוח בבקשות התובעים לאפשר חקירת שתי עדות נוספות, עדיין, בסופו של יום, נחקרה רק אחת מהעדות (הגב' לודביש).
49. עם זאת אבהיר, לתובעים ניתנו מספר הזדמנויות לצורך זימון העדים. בהתאם להחלטתי מיום 20.3.2013 נקבע התיק להוכחות ליום 18.4.2013, כאשר עד ליום 8.4.2013 היה על כל אחד מהצדדים להגיש את רשימת העדים מטעמו. למרות זאת, התובעים לא הציגו כל רשימת עדים, ולכן בדיון ההוכחות שהתקיים בתיק ביום 18.4.2013 ביקשו התובעים להגיש **לראשונה** את שני תצהירים (של הגב' בן ישי והגב' לודביש), כאשר שתי המצהירות לא התייצבו לדיון.
50. יתר על כן, בהחלטתי מיום 20.3.2013 קבעתי כי מיד לאחר דיון ההוכחות יערך גם **ביקור במקום**, ככל שהדבר יידרש. בנסיבות אלה הרי שבסוף הדיון ביום 18.4.2013, נבחנה אפשרות לחקור את שתי המצהירות **בביתן**.
51. למרות זאת, מבירור שערכה התובעת נמסר, כי שתי העדות לא היו בביתן באותו מועד. בשל כך נדרש היה לקבוע **מועד נוסף** לצורך עריכת הביקור במקום וחקירת שתי המצהירות. התובעים נדרשו לצורך כך לתאם מועדים עם שתי העדות לצורך חקירתן בביתן.
52. ואכן בסופו של יום נערך הביקור במקום **במועד שהוצע על ידי התובעים עצמם**. או אז בשל איחור של כ-20 דקות בתחילת הביקור במקום, נטען כי הגב' בן ישי כבר עזבה את



ביתה ולמעשה עד לסיום הביקור במקום וחקירת המצהירה (הגב' לודביש) לא חזרה הגב' בן ישי לביתה ועל כן לא נחקרה.

53. ויודגש, במקרה זה הסכמתי לחקור את שתי המצהירות בביתן וזאת למרות שלא הוצג, כאמור, כל מסמך רפואי המלמד כי לא היה באפשרות המצהירות להתייצב בלשכתי כדי להחקר על תצהירן. יתר על כן, העובדה כי העדה גב' בן ישי לא שהתה בביתה, הן במועד דיון ההוכחות הראשון (18.4.2013) והן במועד השני שתואם עימה (8.5.2013) מעידה כי לא הייתה מניעה ממשית כי עדה זו תתייצב להחקר בלשכה.

54. יתר על כן, אפילו הייתי מקבל את התנגדותה של הגב' בן ישי (ואינני מקבל התנגדות זו) מאותם טעמים שפורטו לעיל ומשלא נחקרה על תצהירה, הרי שעדיין היה לנתבע את הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירתו, שכן היה לו רוב של $\frac{6}{8}$ מבעלים הדירות אשר להם $\frac{79}{100}$ חלקים מהרכוש המשותף (החלקים של התובעים הנם $\frac{11}{100}$ וכן של גב' בן ישי $\frac{10}{100}$). חלקים אלה עומדים ברוב הדרוש לפי סעיף 71ב (75% מבלי הדירות שלהם $\frac{2}{3}$ מהרכוש המשותף). כפי שציינתי לעיל, ממילא יש לדחות את התנגדותה של הגב' לודביש, לאור עדותה בה אישרה למעשה כי היא עצמה אינה מתנגדת, ובהעדר טעם ממשי להתנגדות מצידה.

הנטל לאשש או להפריך חתימה

55. יש לדחות את טענת התובעים, כי היה על הנתבע לזמן את בעלי הדירות החתומים על הבקשה להיתר שהגיש, כדי לאשר את חתימתם. שעה שהוצג המסמך המעיד על חתימת בעל הדירה ולאור עדות הנתבע כי בעלי הדירות חתמו בפניו על ההסכמה, הנטל להפריך את ההסכמה הועבר לכתפי התובעים.

56. יתר על כן, מהאישורים שצורפו לבקשה לסעד זמני, אישרו אותם שכנים את חתימותיהם על התוכנית, ולכל היותר ביקשו לחזור בהם מהסכמות שנתנו ו/או טענו חלקם כי הוטעו. ודאי שבנסיבות כאלה מוטל היה על התובעים לזמן עדים אלה למתן עדות.

57. אין בדעתי לקבל את טענת התובעים כי יש ליתן את אותו משקל ראיתי לחתימת בעלי הדירות על הבקשה להיתר של הנתבע, כמו זה הניתן למכתבים עליהם חתמו השכנים בהם התנגדו בחלקם לבנייה המבוקשת.

58. חתימה על בקשה להיתר מצד בעל דירה הינה בעלת נפקות ומשקל ממשיים. ברי למי שחותם על בקשה להיתר, כי מבקש ההיתר מסתמך על חתימה זו ועל בסיסה משקיע הוצאות רבות לצורך קבלת ההיתר. בנוסף, חתימה זו נועדה לשמש אסמכתא של ממש כדי להציג בפני מוסדות התכנון. על כן, לצורך חזרה מהסכמה שכזו לא די במכתב שבו מבוקש לחזור מההסכמה.



אופן קבלת ההסכמה

59. התובעים טוענים עוד כי הסכמה להרחבת דירה יש לקבל במסגרת אסיפה כללית, ולא די בהחתמת בעלי הדירות על הבקשה להיתר. גם טענה זו יש לדחות.

60. בלשון סעיף 71ב לחוק אין כל עיגון לדרישה זו, שגם אינה עולה לשיטתי מהתכלית העומדת בבסיס הסעיף ו/או אינה מתחייבת מהגיונם של דברים. זאת ועוד, במקרים אחרים, כאשר ביקש המחוקק כי הסכמה מסוימת תתקבל במסגרת אסיפה כללית, קבע זאת במפורש (כך למשל לעניין התקנת מעלית – סעיף 159 לחוק).

61. אוסיף ואומר כי לטעמי, לעיתים החלטה של בעל דירה להסכים או שלא להסכים להרחבת דירה תעשה באופן חופשי יותר ונטולת לחצים, דווקא כאשר הפנייה אליו נעשית באופן אישי. פעמים מבקש החתימה מגיע לדירתו, כך שיש לו השהות והזמן הדרוש לבחון הבקשה לגופה, לשקול אותה ואף להתייעץ עם שכניו. דווקא דיון בנושאים מסוג זה באסיפה כללית, עשוי ליצור לחצים וסד זמנים קצר יותר למתן החלטה בנושאים שמועלים לדיון במסגרת האסיפה.

62. ואכן, בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע כי הסכמת בעלי דירות להרחבת דירה אינה צריכה להתקבל במסגרת אסיפה כללית (כך למשל פסה"ד שלבית משפט השלום בירושלים בת"א (י-ס) 2998/04 **כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור חביב אורי** (פורסם בנבו), כך גם פסק כב' המפקח הבכיר ש' הייזלר בפרשת **מור**. ע"א (י-ס) 1415/00 **אברהם נ' אזרד** (לא פורסם) וכן גם פסק דינה של כב' המפקחת י' ליבוביץ בתיק 87/11 (חי') **גבריאל נועם ואח' נ' בוזגלו איריס ואח'** (פורסם בנבו), בשא (י-ס) 8251/07 **שטיין עמוס נ' קוצר אסנת** (פורסם בנבו) כן תא (י-ס) 14565/06 **משה שמחוביץ נ' שפרה גיל** (פורסם בנבו) וכן ר' פס' דינה של כב' המפקחת י' ענתבי-שרון בתיק 178/08 **שרה (ג'ו) שפירא נ' יעקב אריה ואח'**, פסק דין פורסם באתר משרד המשפטים).

63. **התוצאה** – מכל האמור לעיל עולה כי לנתבע יש את הרוב הדרוש לצורך בניית המרפסת וזאת בהתאם לסעיף 71ב לחוק.

שלב ב' - פגיעה מהותית

64. משמצאתי כי יש בידי הנתבע את הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירתו, נותר לי לבחון אם בניית המרפסת עולה כדי "פגיעה מהותית" בקניינם של התובעים כמשמעותה בסעיף 71ג לחוק.



65. סעיף 71ג לחוק המקרקעין מאפשר לבעל דירה הטוען, כי הרחבת הדירה תגרום לפגיעה מהותית בזכויותיו, להגיש תביעה למפקח ולהוכיח כי הבניה הנטענת תפגע בו, כאמור, באופן מהותי. במצב כזה, מוסמך המפקח, בנסיבות מסוימות, גם למנוע את אותה בניה וזאת הגם שיש בידי בעל הדירה את הרוב הדרוש לצורך ביצוע ההרחבה המבוקשת.

66. המלומד א' איזנשטיין מגדיר "פגיעה מהותית" כ:

"פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עימו גם תמורת פיצוי כספי הולם, כגון הסתרת אור, אויר, נוף מטרד מתמשך וכו'" (אריה איזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין" (חלק שלישי – בתים משותפים) 218 (2001), כן ר' עו"ד עוז כהן "בתים משותפים" (מהדורה שנייה) 189 (2009) והדוגמאות שם).

67. בנוסף, בתיק 318/00 (ח"י) אלון ואסתר טוקניץ נ' שרה גת (פורסם בנבו) קבעה כב' המפקחת הבכירה צ' פיגנבוים, כי ירידת ערך לאחר ביצוע הבניה המבוקשת לעומת שווי הדירה עובר לבניה, עשויה להחשב כפגיעה מהותית, אך לצורך ביסוס טענה זו יש להביא חוות דעת בעניין.

68. בכל מקרה, במסגרת סעיף 71ג לחוק, לא הסתפק המחוקק בכל פגיעה, אלא כאמור דרש קיומה של "פגיעה מהותית", וזו אינה קיימת כלל ועיקר בנסיבות המקרה שבפניי. בעניין זה ר' גם דבריה של כב' המפקחת י' ענתבי-שרון בתיק 178/08 שרה (ג'ו) שפירא נ' יעקב אריה ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים):

"מטבע הדברים כמעט כל בניה שהיא בבית משותף עשויה לגרום אי נוחות או פגיעת מה בבעל דירה זה או אחר, וזהו חלק טבעי ממרקם החיים בבית המשותף".

69. יישום כללים אלה על נסיבות המקרה שבפניי, לרבות דוגמאות ופסקי דין אליהם מפנה עו"ד עוז כהן בספרו הנ"ל, מלמדים כי בענייננו אין מדובר בפגיעה מהותית כלל ועיקר, וספק אם ניתן אף לראות בכך משום פגיעה ממשית בקניינם של התובעים.

70. למסקנה זו הגעתי על סמך הראיות שהוגשו בפניי, לאחר שעיינתי בבקשה להיתר ובתמונות שהוצגו, ובמיוחד מהביקור במקום שערכתי בנכס. אוסיף, כי התובעים לא צרפו כל חוות דעת שיש בה כדי ללמד על הפגיעה הנטענת.

71. התובעים טוענים כי בניית המרפסת תפגע בהם באופן מהותי, מרפסת דירתם תהא "מוקפת" מכל עבר במרפסת הנתבע, ובגין כך יוגבלו השימושים שיוכלו לעשות במרפסת כמו למשל הצבת עציצים (בשל חשש שיפלו חפצים או מהטעם שהשקיית העציצים תגרום ללכלוך וסכסוכים מתמשכים עם הנתבע). כך לא יוכלו לנקות שטיחים במרפסת וכן



לטענתם לא יוכלו להתהלך במרפסת בבגדים לא צנועים מחשש שיראו אותם (עמ' 4 לפרוט' מיום 18.4.2013). התובעת חזרה ופירטה בעדותה בפניי את הפגיעות שלטענתה תגרום בניית המרפסת. עוד נטען כי המרפסת תגרום למטרדי רעש וריחות, כאשר הנתבע יעשה "מנגל" במרפסת.

72. אלא שכאמור מהביקור במקום שערכתי במקום, אשר במסגרתו נערך סיור בכל אחת מהדירות וכן בגינת הנתבע, התברר בצורה חד משמעית, כי הפגיעה בקניינם של התובעים תהיה מינימאלית, אם בכלל.

73. אציין כי במועד הביקור במקום כבר הוסר גג הרעפים, שבמקומו עתידה להבנות המרפסת (שכן הדבר נעשה טרם הגשת הבקשה לסעד זמני ו/או בהתאם להסכמות שהתגבשו במסגרת הדיון בבקשה לסעד זמני ביום 20.3.2013), כך שניתן היה להיווכח בצורה ברורה ונהירה יותר מה יהיה מצב הדברים ככל שתבנה המרפסת.

74. מהביקור במקום גם עולה כי המרפסת, אותה מבקש הנתבע להקים, תחרוג מחזית מרפסת התובעים **בכמטר עד מטר וחצי** לכל היותר (עמ' 2 לפרוט' מיום 8.5.2013, ש' 17 – 19) וגם זאת **מבלי לחרוג מקונטור הגג הקיים כיום של דירת הנתבע**, כפי שזו כבר הורחבה בעבר.

75. מכאן, **המרפסת המבוקשת לא תיצור "בליטות" חדשות ולא תחרוג מקווי הבניין הקיימים כיום בבניין**. בקשת הנתבע הינה להגדיל את המרפסת הקיימת על גבי אותה שטח גג של היחידה כפי שכבר קיים מספר שנים. בנוסף, המרפסת אותה מבקש הנתבע לבנות לא תהיה ממוקמת ישירות מתחת לחלון דירת התובעים, אלא מתחת למרפסת דירתם בלבד.

76. הרחבת המרפסת על ידי הנתבע לא תמנע מהתובעים להמשיך ולעשות שימוש סביר במרפסת דירתם, לרבות הצבת עציצים במקום בצורה בטיחותית.

77. זאת ועוד, קיומן של מרפסות מדורגות הינו אופייני ושכיח בבתים משותפים רבים, כך שיצירת מצב של מרפסת מדורגת בין דירת התובעים לדירת הנתבע אינה עולה כדי פגיעה מהותית בקניינם, במיוחד בנסיבות מקרה זה שבו "הבליטה" ביחס למרפסת דירת התובעים תגיע לעד כ-1.5 מטר לכל היותר.

78. יתר על כן, מרפסות מדורגות קיימות אף בבניין נשוא הליך זה. כך קיים ביחס שבין מרפסת דירת התובעים שבקומה השנייה, לדירת השכנים שמעליהם בקומה השלישית (כפי שגם עולה מנ/2, על אף שבפועל בעלי הדירה מעל התובעים סגרו במשך הזמן את מרפסת דירתם. כך גם עולה מחזית השנייה של הבית המשותף ר' נ/2, שם נבנו מרפסות מדורגות, בין הקומה השלישית לשנייה).



79. מפגעי רעש וריח שמבקשת התובעת לייחס למרפסת אינם ברורים ולא הובאו ראיות לשימוש שהוא חורג משימוש רגיל במרפסת בלתי מקורה. בנוסף, מרפסת הנתבע אינה ממוקמת ישירות מתחת לחלון דירת התובעים, אלא מתחת למרפסת דירתם בלבד.

80. זאת ועוד, כבר כיום קיימת מרפסת בדירת הנתבע **מתחת לדירת התובעים** כך שגם ממנה יש אפשרות לעשות "מנגל" (התובעים לא טענו ולא הוכיחו כי מטרדים כאלה קיימים כבר כיום). כל בקשת הנתבע הינה להרחיב את אותה מרפסת פתוחה, שממילא קיימת כבר היום מתחת למרפסת התובעים, למרפסת פתוחה גדולה יותר.

81. זאת ועוד, גם כיום מתחת למרפסת דירת התובעים קיימת גינת הנתבע, כך שהחשש מנפילת דברים, לכלוך, ניקיון שטיחים וכדומה, ממילא קיים כבר כיום. דברים שנופלים ממרפסת הנתבע נופלים לגג הרעפים ומשם לגינת הנתבע. ממילא מי שבבעלותו מרפסת אינו אמור להיות אדיש לנפילת חפצים או לכלוך מהמרפסת, שכן אלו נופלים לכל הפחות לרכוש המשותף. בנוסף, העובדה שהתובעים "יאלצו" להתקין תימוכין בטיחותיים לאדניות, אינו מהווה פגיעה מהותית בקניינם.

82. לא השתכנעתי כי בניית המרפסת תפגע בפרטיותם של התובעים ובשימושם במרפסת דירתם. דווקא מהרחוב עצמו ניתן לראות בצורה טובה בהרבה את שמתרחש במרפסת דירת התובעים על פני "תצפית" ממרפסת הנתבע, שממנה יהיה קשה עד מאוד אם בכלל לראות את שמתרחש במרפסת, נוכח זווית הראיה והיחס שבין המרפסות.

83. בנוסף, החלק הדרומי הקיים של מרפסת הנתבע אמור לשקף באופן מסוים את שיהיה בעתיד בחלק הצפוני של אותה מרפסת. מהחלק הדרומי קשה לראות ממרפסת הנתבע את שמתרחש בחזית הדרומית של מרפסת התובעים, ובכלל קשה להתרשם מהפגיעה הנטענת.

84. על אחת כמה וכמה, לא ניתן יהיה לראות באופן חופשי את שמתרחש בתוך חדר בנם של התובעים. חלון חדר הנתבע כלל אינו נמצא ישירות מעל המרפסת. הגובה והמרחק בין המרפסת לחלון, צורת החלון וגודלו, אינם מאפשרים תצפית שכזו בהעדר כוונת מכוון. הביקור במקום כלל סיור בתוך דירת התובעים, לרבות בחדר של בנם. מחלון החדר לא ניתן לראות כלל את המרפסת, אותה מבקש הנתבע לבנות, אלא רק אם מתכופפים החוצה.

85. אני דוחה אם כן את טענות התובעים בכל הנוגע להגבלות השימוש במרפסתם. בעניין זה גם קבעה הוועדה המקומית, לאחר שבחנה את הבקשה, כי:

"מפלס הגג המדובר נמוך משמעותית (הפרש גובה של קומה אחת) בין מפלס דירת המתנגדת למפלס הגג המדובר. הוועדה אינה סבורה שיש לקבל את הטענה שלפיה, המתנגדים לא יוכלו להשתמש במרפסתם"



86. אכן, השיקולים שעלי לבחון שונים מהשיקולים התכנוניים, אך בכל הנוגע לפגיעה הנטענת ובשים לב לטיב הטענות המועלות, יש בנימוקי הוועדה כדי לחזק המסקנה אליה הגעתי.

87. **התוצאה** - הביקור במקום הדגיש במיוחד כי הפגיעה, ככל שקיימת, הינה פגיעה שולית בלבד, שלא לומר כמעט בגדר "זוטי דברים", ובכל מקרה ודאי שאינה עולה כדי "פגיעה מהותית". קומה שלמה מפרידה בין מרפסת הנתבע לדירת התובעים (גובה של כ-3 מטר בין רצפת שתי המרפסות), **המרפסת תבנה על שטח גג קיים ולא תחרוג ממנו**. המרפסת של הנתבע תחרוג לכל היותר בכמטר עד מטר וחצי מקו מרפסת התובעים. עסקינן בהרחבתה של מרפסת שכבר קיימת. כל אלה מובילים למסקנה כי לא ניתן לראות בבניית המרפסת משום פגיעה מהותית בקניינם של התובעים.

88. העובדה שלנתבע קיימות מרפסות נוספות אינה שוללת ממנו הרחבת המרפסת, ובלבד שעמד בתנאים עליהם עמדתי בפסק דין זה.

89. **בנסיבות אלה, התובעים לא הוכיחו כי בניית המרפסת תגרום לפגיעה מהותית בקניינם בהתאם לסעיף 71ג לחוק.**

90. הערה לסיום: התובעים טוענים שהבקשה להיתר אושרה בוועדה המקומית וזאת בשל "קשריו" של הנתבע בעיריית נהריה. נושא זה לא נדון בפניי וממילא כלל אינו רלבנטי להליך שבפניי, כך שאינני רואה צורך לדון בו וספק אם היה מקום להעלותו. במסגרת סמכותי הריני מוסמך לדון בשאלה, אם בפן הקנייני ומבחינת חוק המקרקעין, רשאי הנתבע להרחיב את דירתו על דרך בניית המרפסת, והאם יש בבניית המרפסת משום פגיעה מהותית בקניינם של התובעים.

91. למעלה מן הצורך אציין, כי ככל שהתובעים סברו כי הוועדה המקומית שקלה במסגרת החלטתה שיקולים שלא מן העניין, הרי שהיו רשאים להגיש ערר לוועדת הערר המחוזית, בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ו/או להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט. משבחרו התובעים שלא למצות את הליך ה"רישוי" של הוצאת ההיתר, ודאי שאין מקום לאפשר להם להעלות בעקיפין טענות נגד ההיתר שניתן במסגרת ההליך שבפניי, מה גם שהדבר אינו בסמכותי, והטענה הועלתה בעלמא ללא כל תימוכין.



לסיכום :

92. הנתבע רשאי להרחיב את דירתו על דרך הרחבת המרפסת, וזאת בהתאם להיתר הבניה שניתן לו על ידי הוועדה המקומית ביום 23.1.2013 (בקשה מס' 20120218).

93. צו המניעה שניתן ביום 11.3.2013 וצומצם בדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 20.3.2013 מבוטל בזאת.

94. הנני מחייב את התובעים לשלם לנתבע הוצאות ההליך, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך **6,000 ₪**. סכום זה ישולם לנתבע תוך 45 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום, י"ב תשרי תשע"ד, 16 ספטמבר 2013.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין